



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 366/16

בענין:

1. לבנה אמנון
2. מונה לבנה אודליה

הנתבעים
נתבעים שכנגד

מרח' הרופא 46, חיפה

נ ג ד

1. קופרשמידט אורי
2. קופרשמידט תמר

הנתבעים
תובעים שכנגד

ע"י עו"ד הדר פינק טבת ואח'
מרח' ביאליק 3, חיפה 331122
טל': 077-4049484, פקס: 077-4049181

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים, שהם בעלים של דירה בבית המשותף ברח' הרופא 46, חיפה, המזוהה כחלקה 11 בגוש 10778 (להלן: "הבית/המשותף") הגישו תביעה בה עתרו למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית, לסלק ידם ממעבר תת קרקעי לביוב אותו סיפחו עפ"י הנטען לדירתם.
2. הנתבעים הגישו תביעה שכנגד בה עתרו לחייב את התובעים/הנתבעים שכנגד בסך של 38,000 ₪ בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירתם בעטיו של ליקוי שהיה קיים בדירת התובעים ושתוקן אך לאחרונה.
3. ביום 31.1.16 שלחו הנתבעים הודעה בעטיה נמחקה התביעה שכנגד ללא צו להוצאות.

תמצית טענות התביעה-

4. עפ"י מסמכי רישום הבית המשותף מהווה המעבר התת קרקעי לביוב רכוש משותף. יש להורות לנתבעים, אשר השתלטו על שטח משותף זה, להשיב שטח זה לחזקת כל בעלי הדירות בבית.
5. לנתבעים לא נתונה הסכמה בשיעור הדרוש עפ"י חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לעשיית שימוש ייחודי בשטח מעבר הביוב או לצורך הרחבת דירתם על חשבון שטח זה.

6. עד לקיומו של ההליך בעלי הדירות בבית כלל לא ידעו על השימוש שעושים הנתבעים במעבר לביוב. אפילו יוכח שהייתה קיימת לנתבעים רשות לעשיית שימוש בשטח זה, הרי שמדובר ברשות הדירה אשר ניתן לבטלה בכל עת.

7. אין לראות את התובעים כמי שביצעו "הרחבה דומה" כמשמעות מונח זה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, אמנם התובעים סגרו שטח מקורה של כ-32 מ"ר בדירתם, עם זאת כל בעלי הדירות בבית ביצעו סגירה זהה.

תמצית טענות ההגנה-

8. הבית נבנה בשנות השבעים של המאה הקודמת ומיום שנבנה העניק הקבלן את החזקה במעבר התת קרקעי לביוב (להלן: "המעבר לביוב") לבעליה הקודמים של דירת הנתבעים. הדירה נמכרה על ידי הרוכש הראשון וזה העבירה לאחר אשר העבירה לידי הנתבעים. הדירה הועברה כשהיא כוללת את שטח המעבר לביוב.

9. מיום שנבנה הבית התגורר בדירה מדירות הבית אביה של התובעת ובתקופות מסוימות גרה עמו כילדה ביתו היא התובעת. לאור זאת דבר שיוכו של המעבר לביוב לדירת הנתבעים היה ידוע לשניהם.

10. מיום שהבית הוקם ועד היום הגישה היחידה הקיימת למעבר לביוב היא מדירת הנתבעים.

11. נקודת המפנה בעטיה הוגשה תביעה זו היא דרישתם של הנתבעים מהתובעים לתקן ליקוי בדירתם שהביא לנזקי רטיבות בדירת הנתבעים ולפצותם על נזקיהם.

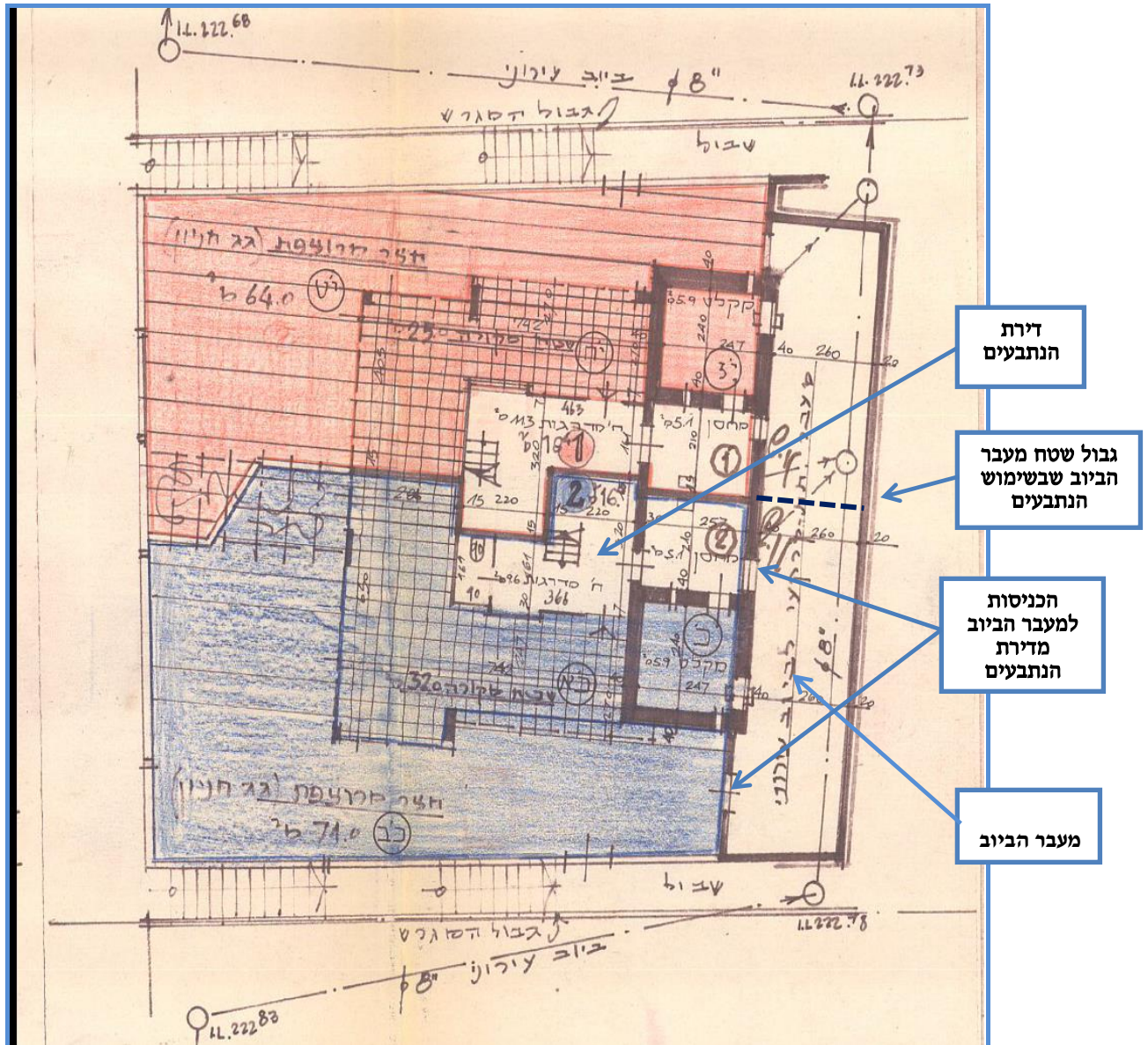
12. בעקבות ההליך ובהמלצתי כונסה בבית אסיפה כללית של בעלי הדירות, על מנת לבחון את הסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית להרחבת דירת הנתבעים על חשבון שטח מעבר הביוב. בעקבות אותה אסיפה המציאו הנתבעים טפסים הנושאים את חתימתם של 13 מ-16 בעלי דירות בבית בהם ניתנה לנתבעים הסכמה לעשיית שימוש ייחודי בשטח מעבר הביוב.

13. בנוסף, יש לראות את התובעים כמסכימים להרחבת דירת הנתבעים על חשבון שטח מעבר הביוב, היות והתובעים ביצעו "הרחבה דומה" עת הוסיפו כ-27 מ"ר בניה לדירתם.

14. יש לדחות את תביעת התובעים תוך קביעה כי המעבר לביוב מהווה חלק בלתי נפרד מדירת הנתבעים.

ההליכים בתיק-

15. למקרא חומר הראיות בתיק מצאתי לקיים ביום 11.2.16 ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. טרם שאסקור את ממצאי הביקור במקום, ועל מנת להקל על הבנתם, מצאתי למוזג בפסק דיני קטע מתשריט רישום הבית המשותף. על התשריט הוספו הערותיי.



(א) מדובר בבית משותף המורכב משני מבנים. מבנה קדמי בן 10 יחידות שחזיתו פונה לרח' הרופא, ומבנה נוסף בן 6 יחידות המצוי בעורף המבנה הקדמי. דירות הצדדים להליך מצויות במבנה הקדמי. דירת התובעים ידועה כתת חלקה מס' 4 ודירת הנתבעים כתת חלקה מס' 2.

(ב) החלקה בנויה בשיפוע חד, ומהרחוב מובילים 2 גרמי מדרגות דרכם עולים אל הבית ודירותיו.

(ג) דירת הנתבעים משתרעת על פני שלוש קומות כאשר הכניסה לדירה היא מהקומה הראשונה. באותו מפלס קיים מעבר הביוב המצוי בסמיכות פיזית לתתי חלקות מס' 1 ו-2 והוא נמצא מתחת לחצרות הצמודות לתתי חלקות 3 ו-4.

(ד) מחצית משטח המעבר לביוב סופח לדירה תת חלקה מס' 2 שבבעלות הנתבעים ומשמש אותם כמחסן.

(ה) הכניסות היחידות הקיימות לשטח מעבר הביוב הן מתוך דירת הנתבעים או מתוך הצמדה כב' הצמודה אף היא לדירת הנתבעים. (היות ודירה תת חלקה מס' 1 אינה צד להליך לא נכנסתי לדירה זו על מנת להתרשם האם קיימת כניסה גם ממנה למעבר הביוב).

(ו) הופנתי אל שטחים מקורים המצויים סמוך לכניסה לדירות הצדדים להליך, אשר עפ"י הנטען נסגרו והתווספו לשטחי הדירות.

16. ביום 14.6.16 התקיים דיון הוכחות בתיק במהלכו העידו התובעת, הנתבעים ומספר בעלי דירות נוספים בבית. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

17. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה, בתנאים כפי שיפורטו מטה. להלן נימוקי הכרעתי:

18. בעטיו של ההליך כינסו בעלי הדירות בבית אסיפה כללית בה ביקשו הנתבעים לקבל את הסכמת בעלי הדירות בבית לעשיית שימוש בשטח מעבר הביוב. טופסי החתימות שהתקבלו מאת בעלי הדירות בבית הוגשו וסומנו ת/2 (להלן: "טופסי ההסכמה"). להלן הנתונים שעלו מטופסי ההסכמות:

19. בעליהם של תתי חלקות מס': 1, 7, 8, 11, 13, 15, 16 חתמו על טופס הסכמה בו נקבע כדלהלן: **"אנחנו הח"מ מסכימים ומאשרים בזאת את השימוש של בעלי דירה 2 בבניין הרופא 46 במחסן/שטח "המעבר התת-קרקעי לביוב העירוני", הצמוד לדירה מכיוון מזרח, בהסכמה בלתי חוזרת, אך ורק לשימוש כפי שהיה עד היום, ולראיה באנו על החתום:"**

20. המדובר אפוא בהסכמה בלתי מותנית וניתן לראות בה הסכמה להקנות לנתבעים את מלוא זכויות השימוש בשטח מעבר הביוב. הסכמה זו כמוה כרשות להוצאת חלק זה מהרכוש המשותף לצורך הצמדתו לדירת הנתבעים.

21. הבעלים של תת חלקה מס' 3 חתם על טופס הסכמה בו נקבע כדלהלן: "אנחנו, אורי ותמר קופרשמידט, החתומים מטה, מבקשים להשתמש במעבר התת-קרקעי לביוב הצמוד לדירה 2. לחתום מטה אין לכך התנגדות".

ובהמשך נכתב - "אנחנו, אורי ותמר קופרשמידט, החתומים מטה, בעלים של דירה מס' 2 ברחוב הרופא 46, מצהירים בזאת שידוע לנו שהשטח מוגדר "מעבר תת-קרקעי לביוב העירוני", הצמוד לדירה שלנו, הנו רכוש משותף של כל דיירי הבית המשותף. אנחנו מתחייבים שהחתימה על טופס ההסכמה לשימוש על-ידינו בשטח האמור, לא תביא אתה כל הוצאה כספית או מחויבות אישית אחרת לחותמים."

22. הבעלים של תתי חלקות מס': 6, 9, 10, 12 חתמו אף הם על טופס הסכמה בו נקבע כדלהלן: "החתום מטה מצהיר בזאת שלא ביקש ולא יבקש להשתמש ב"מעבר התת-קרקעי לביוב העירוני" כרשום בטאבו, שמהווה חלק משטח הבית המשותף, צמוד לדירה מס' 2, ומרשה לדיירים של אותה דירה להמשיך להשתמש בשטח, כפי שהיה עד עכשיו."

ובהמשך נכתב - "אנחנו, אורי ותמר קופרשמידט, החתומים מטה, בעלים של דירה מס' 2 ברחוב הרופא 46, מצהירים בזאת שידוע לנו שהשטח מוגדר "מעבר תת-קרקעי לביוב העירוני", הצמוד לדירה שלנו, הנו רכוש משותף של כל דיירי הבית המשותף. אנחנו מתחייבים שהחתימה על טופס ההסכמה לשימוש על-ידינו בשטח האמור, לא תביא אתה כל הוצאה כספית או מחויבות אישית אחרת לחותמים."

23. מההסכמות המפורטות בסעיפים 21 ו-22 לעיל נהיר כי בעלי הדירות שחתמו על הסכמות אלו עמדו על כך ששטח מעבר הביוב יוותר רכוש משותף ולנתבעים תינתן רק הרשות להמשיך ולהשתמש בשטח.

24. על בסיס הסכמות אלו ביקשו הנתבעים כי אראה בהוספת שטח מעבר הביוב לדירתם בבחינת "הרחבת דירה", הטעונה הסכמתם של 3/4 מבעלי הדירות בבית שלהם צמודים 2/3 מהחלקים ברכוש המשותף. לטענתם, ההסכמה שניתנה להם היא בשיעור העולה על הרוב הדרוש לצורך הרחבת הדירה.

25. לעניין הרחבת דירה מורנו סעיף 72ב(א) שבסימן 11 לחוק המקרקעין כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות". (הדגשה שלי י.ל.)

26. לא מצאתי כי הנתבעים הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם להוכיח כי ניתן לראות בחיבור שטח המעבר לביוב לדירתם בבחינת "הרחבת דירה", וזאת משני טעמים: ראשית, בסעיף 71א. לחוק המקרקעין מוגדת "הרחבה" – "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". הנתבעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי ניתן לקבל היתר בנייה להוספת שטח מעבר הביוב לדירה. שנית, לצורך החלת סעיף 72ב(א) לחוק המקרקעין נדרש כי בעלי הדירות בבית, ברוב האמור בסעיף, ייתנו הסכמתם להוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירת הנתבעים. מתוכן ההסכמות שהובאו לעיל עולה כי 7 בעלי דירות בבית וכן הנתבעים בעצמם מסכימים הסכמה גורפת לכך ששטח המעבר יוצמד לדירת הנתבעים. הסכמה זו תואמת את האמור בסעיף 72ב(א) לחוק המקרקעין, אך היות ובבית 16 בעלי דירות, הסכמות בשיעור הנ"ל מהוות 50% בלבד מקרב בעלי הדירות בבית והן אינן מגיעות לשיעור ההסכמה הדרוש עפ"י חוק. יתר בעלי הדירות בבית נתנו הסכמה לכך שהנתבעים יעשו שימוש באותו השטח, אך עמדו על כך שהשטח יוותר רכוש משותף. לדידי, תוכן ההסכמות של יתר בעלי הדירות בבית אינו עולה כדי "הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה.", אלא מהווה הסכמה לעשיית שימוש בלבד, שאינו עולה בקנה אחד עם דרישת סעיף 72א(1) לחוק המקרקעין.

27. משמצאתי כי אין מדובר ב"הרחבת דירה" כמשמעות המונח בחוק המקרקעין מצאתי לבחון האם נוכח התשתית העובדתית מושא ההליך, יש להיעתר לבקשת התובעים להורות על סילוק ידם של הנתבעים מהשטח המשותף בו הם מחזיקים חזקה ייחודית?

28. סעיף 14 לחוק המקרקעין קובע כי:

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר."

29. סעיף 16 לחוק המקרקעין קובע כי:

"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין."

30. ענינו הרואות כי בעוד שסעיף 14 לחוק המקרקעין מגביל את כוחה של הבעלות, ומונע מבעלים של נכס לעשות שימוש לרעה בזכותו, מקנה סעיף 16 לחוק המקרקעין לבעל מקרקעין את הזכות לפעול לסילוק ידו של פולש ממקרקעין.

31. לאורם של סעיפים שונים אלו עולה השאלה האם עומדת לתובעים זכות מוחלטת לדרוש השבת המצב לקדמותו וסילוק ידם של הנתבעים משטח מעבר הביוב, אשר אין מחלוקת כי הוא רכוש משותף, או שנכון להפעיל מנגנון מאזן שיביא בחשבון גם את עוצמת הזכות, אינטרסים של המחזיקים ושיקולים של צדק והגינות?

32. שאלה דומה עמדה לדיון בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (פורסם במאגרים המשפטיים). באותו פסק דין דובר בבנייה שביצע הפולש במקרקעין שבבעלות אחר. בית המשפט, בפסק דינו הארוך והמנומק, הביא סקירה רחבה של עקרון תום הלב בכלל ושל אופן כפיפותה של זכות הקניין לעקרון זה בפסיקה. מוצאת אני לצטט מפסק הדין את הקטע שלהלן שחשוב ונכון גם לצורך הכרעתי:

"חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית. לכן, 'אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם 'הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת' "(עניין רוקר, 277). ובמילים אחרות, בעל-דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחויב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר (ראו שם, 279. כן השוו ענין גנז, 404-408). יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול-דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית."

33. וראו גם את פסקי הדין אליהם הפנה בית המשפט בפסק דינו זה.

34. בהקשר זה נכון אף להפנות לפסק דינו של כב' השופט טירקל רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 אשר קדם לפס"ד טורקיה בו קבע בית המשפט ארבעה שיקולים אשר לדעתו ראוי שינחו את הפעלת שיקול דעתו של בית המשפט במקרים כגון דא:

"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי - משני בחשיבותו לקודמיו - הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין" (שם, 242).

35. על רקע עקרונות אלו אפנה ואבחן את נתוני תביעה זו.

36. עיון במסמכי רישום הבית המשותף מעלה כי שטח מעבר הביוב רשום כרכוש משותף. בעניין זה גם לא הייתה מחלוקת בין הצדדים.

37. אמנם, מדובר על שטח אשר מבחינה קניינית אינו שייך בלעדית לנתבעים, עם זאת, לטעמי, קיימים נתונים נוספים אשר בהצטברם מטים הם את הכף לטובת הותרת המצב הקיים על כנו.

38. מחומר הראיות עלה כי הבית נבנה בשנות השבעים, וכי החל מהמועד שנבנה ניתנה/ניטלה החזקה בשטח מעבר הביוב למי שהיו באותו המועד הבעלים בדירת הנתבעים. בעניין זה ראו עדותו של מר פרומר, מי שהיה בעלים קודם בדירת הנתבעים, והעיד כי במועד בו רכש את הדירה שימש שטח מעבר הביוב כמחסן

של הדירה. מר פרומר העיד כי שטח זה שימש גם את הבעלים שקדם לו, מר שרייבר, כמחסן-חדר עבודה. עוד עלה מעדותו כי כבר מהמועד בו היו שרייבר הבעלים הכניסה לשטח מעבר הביוב הייתה מתוך הדירה או מתוך החצר הצמודה לה, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 8-20. עדותו הייתה אמינה עלי, ולא נסתרה.

39. מר שמע, בעלים של דירה בבית, העיד כי הוא גר בבית משנת 1978 וכי כבר משי שרייבר, הבעלים הראשון בדירת הנתבעים, עשו בשטח מעבר הביוב שימוש עת הציבו בו שולחן פינג פונג פרטי, ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 17-22.

40. הנתבע 1 העיד כי במועד הרכישה שימשה מחצית שטח מעבר הביוב כמחסן של הדירה, וכי במועד הרכישה של הדירה סבר לתומו כי הכיתוב "דירה+מחסן" בנסח הרישום מתייחס לשטח זה. לטענתו רק בעקבות הגשת התביעה הסתבר לו כי ה"מחסן" האמור בנסח הרישום אינו מתייחס לשטח מעבר הביוב (ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 5-12). הנתבע 1 הסביר כי טעותו נבעה מהסתמכותו על מספר מסמכים מהם עלה כי מעבר הביוב מהווה מחסן של הדירה: מסמך אחד הוא חוות דעת שמאית שערך שמאי מטעם הבנק ממנו נטל משכנתא בו נרשם כי לדירה מחסן בשטח של 19 מ"ר (שטח תואם לשטח מעבר הביוב), הוגש וסומן 5/נ, ומסמך שני הוא תשריט שמסר לידיו מוכר הדירה במועד הרכישה, בו מופיע מעבר הביוב כחלק מדירתו כשרשום עליו "מחסן", הוגש וסומן 3/נ.

41. אמנם לא הוכח מהו אותו תשריט 5/נ ועל ידי מי נערך, וגם שמאותו של השמאי אין בה כדי להקנות לנתבעים בעלות במחסן אשר רשום כרכוש משותף, אך לטעמי יש בהם כדי ללמד כי הנתבעים הסתמכו בתום לב על מסמכים אלו. מצאתי לקחת בחשבון עובדה זו במסגרת השיקולים אשר יופעלו על ידי במתן הכרעתי זו.

42. נתון נוסף שחשוב לציון הוא שבביקורי במקום התרשמתי כי מדובר על שטח המשמש שנים רבות את דירת הנתבעים. הריצוף הקיים ויושן חומרי הגלם במקום העידו על כך שלא מדובר על "פגיעה בזכות" או שינויים שבוצעו זה מקרוב.

43. חיזוק לאמור מצוי במסמכי רישום הבית המשותף. הבית המשותף נרשם בשנת 1982, וכבר בתשריט הרישום הודגמו אותם פתחי מעבר לשטח מעבר הביוב מדירת הנתבעים ומהחצר הצמודה להם. עדות לכך שהם היו קיימים כבר אז מצויה בהצהרת עורך התשריט ולפיה "התשריט" – "משקף נאמנה את הבניה ואת כל דירותיו." אף על פי תשריט רישום הבית המשותף אין מדובר ב"פגיעה" חדשה.

44. התובעת לא טענה, וממילא לא הפריכה את טענת הנתבעים, כי מיום שנבנה הבית שטח מעבר הביוב משמש את דירתם.

45. לענין עוצמת הפגיעה בזכות- במניין השיקולים הובאה על ידי בחשבון העובדה שמדובר בשטח משותף "כלוא" אשר מיום שהוקם הבית הגישה היחידה אלו הייתה קיימת מתוך דירות תתי חלקות 1 ו-2 או מתוך שטח הקרקע הצמוד להן והוא מעולם לא שימש את יתר בעלי הדירות בבית. הפועל היוצא הוא שסילוק ידם של הנתבעים משטח זה לא יועיל במאומה למי מבעלי הדירות בבית, ולא יצמיח להם כל הנאה ממנו, בהינתן שממילא אין להם כל גישה אפשרית לשטח זה.

46. בהקשר זה אציין כי אמנם התובעים טענו כי שטח מעבר הביוב מצוי מתחת לדירתם, ומשכך קיימת להם אפשרות להוסיף את שטח מעבר הביוב לדירתם, בבחינת "הרחבה" של הדירה, אך לאחר שעיינתי בתשריט רישום הבית המשותף וביקרתי במקום נחה דעתי כי אין ממש בטענה זו. מתשריט רישום הבית המשותף עולה כי שטח זה אינו מצוי מתחת לדירתם, אלא מתחת לחצר הצמודה להם כך שלא ניתן לחברו אל הדירה באופן שהוא יהווה חלק אינטגרלי הימנה. וראו הדברים שנקבעו ברע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא (פורסם במאגרי מידע) שם נקבע כדלהלן:

"לאחר שבחנו את ההסדר הקבוע בסעיף 71 לחוק המקרקעין ועמדנו על התכליות העומדות בבסיסו ועל שיקולים פרשניים נוספים הצריכים לעניין, הגענו לכלל מסקנה כי הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף שאינו מצוי בסמיכות פיסית לדירה אינה בבחינת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71 לחוק."

47. לאור האמור, אפילו יפונה שטח מעבר הביוב משימושם של הנתבעים, ממילא לא יוכלו התובעים או בעלים של דירה אחרת כלשהי בבית להרחיב דירתם על חשבון שטח זה, ובהיעדר גישה לשטח כלוא זה לא יוכלו בעלי הדירות בבית ליהנות משטח זה גם לא בכל אופן אחר.

48. שיקול נוסף שנלקח על ידי בחשבון לעניין הפגיעה בזכות הוא העובדה שבחלק מטופסי ההסכמה שנחתמו מאשרים בעלי הדירות החתומים כי הם מסכימים לשימוש שעושים הנתבעים במעבר הביוב "כפי שהיה עד היום". בטופסי ההסכמה האחרים שנחתמו מאשרים בעלי הדירות החתומים לנתבעים "להמשך ולהשתמש בשטח". למעשה, 12 מ-16 בעלי דירות בבית מאשרים לנתבעים המשך עשיית השימוש במקום, היינו מחזקים את טענת הנתבעים כי מזה שנים הם עושים ורק הם עושים שימוש במעבר הביוב.

49. זאת ועוד, מתוך 16 בעלי דירות בבית אישרו 13 בעלי דירות (כולל הנתבעים עצמם) לנתבעים את המשך עשיית השימוש במקום. בין אלו שלא נתנו הסכמתם מצויים: התובעים, אביה של התובעת ובעל דירה נוסף, אשר לא התייצבו לדיון ולא הביעו כל עמדה תומכת או מתנגדת לשימוש במעבר הביוב.

50. לעניין התנהגות בעלי הדין- בין השיקולים שהנחו אותי בתיק הייתה גם עדותה של התובעת ממנה עלה כי עד למועד הדיון מעולם לא ביקרה בשטח מעבר הביוב

וכלל לא ידעה מה יש שם. מעדותה עלה כי התביעה נולדה בעקבות כך שהנתבעים פנו אליה לגבי רטיבות בתקרת מעבר הביוב, שאז הסתבר לה ששטח זה מהווה רכוש משותף (ראו עדותה בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 38-40).

51. לאור כל האמור לעיל, ולאור נסיבותיו המיוחדות של תיק זה, מצאתי מקרה זה כמקרה בו נוטה הכף לטובת דחייתה של התביעה לסילוק יד והתרת המשך השימוש שעושים הנתבעים בשטח מעבר הביוב.

52. חשוב להדגיש כי שלילת הסעד של סילוק ידם של הנתבעים משטח מעבר הביוב אין בה כדי להקנות לנתבעים זכות קניינית בשטח זה, אשר יוותר רכוש משותף. על כן, כשיחדלו הנתבעים להיות בעליה של הדירה מושא ההליך, מכל סיבה שהיא, לא יהיו הבעלים החדשים של הדירה רשאים לטעון לזכויות בשטח מעבר הביוב, אלא אם יצליחו לגייס לטובתם את הסכמת הרוב הנדרש על פי הוראות הדין.

53. לאור האמור מורה אני על רישומה של הערה על קיומו של פסק הדין בתת חלקה מס' 2. התובעים יפעלו לרישום ההערה בתוך 30 יום מהיום.

54. כמו כן, אדגיש כי זכותם של הנתבעים להמשיך ולעשות שימוש בשטח מעבר הביוב כפופה לחובה לאפשר, בתיאום מראש, גישה לצנרת הביוב העוברת שם לצורך תחזוקתה, ככל שהדבר יידרש.

55. בנסיבות העניין לא מצאתי ליתן צו להוצאות.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' באב תשע"ו (8.8.16)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין

